

1502378-05.2021.8.26.0005

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... para atendimento de ocorrência de tráfico de drogas, envolvendo dois indivíduos. Que ao chegar ao local, apenas um indivíduo com as características informadas na denúncia anônima foi localizado. Que encontrou entorpecente junto à meia do réu, local informado na denúncia anônima. Que o réu portava dinheiro trocado, quantia aproximada de R\$ 40,00 (quarenta reais) e afirmou que a droga ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502378-05.2021.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502378-05.2021.8.26.0005

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3058664/2021 - 63º D.P. VILA JACUI, 19071271 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Marco Aurélio Sprocato

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo pericial de fls. 46/47, que detectou, no material apreendido junto ao réu, a presença da substância cocaína que se encontra no rol das substâncias entorpecentes definidas pela Portaria 344/1998 da Anvisa e atualizações posteriores.

A autoria é certa.

O réu, interrogado em juízo, declarou que portava droga, 04 (quatro) pinos de cocaína, para uso próprio.

No mesmo sentido, os policiais militares confirmaram que encontraram o réu com o entorpecente apreendido.

A testemunha Danilo declarou que recebeu denúncia anônima acerca de dois indivíduos que estariam traficando drogas. Foram até o local indicado, mas lá só havia um indivíduo, com as características descritas na denúncia anônima. Com ele, encontraram quatro pinos de cocaína, escondidos na meia. Ele trazia consigo dinheiro trocado. Ele declarou que eram para uso pessoal. Reconhece o réu na audiência como o autor da conduta descrita.

A testemunha Erick afirmou que, na data dos fatos, foi solicitado via COPOM, para atendimento de ocorrência de tráfico de drogas, envolvendo dois indivíduos. Que ao chegar ao local, apenas um indivíduo com as características informadas na denúncia anônima foi localizado. Que encontrou entorpecente junto à meia do réu, local

informado na denúncia anônima. Que o réu portava dinheiro trocado, quantia aproximada de R\$ 40,00 (quarenta reais) e afirmou que a droga seria para consumo próprio. Reconheceu o réu em audiência.

Do interrogatório do réu e do relato seguro e coeso dos policiais, pode-se extrair, com a certeza necessária, que o réu trazia, consigo, o entorpecente apreendido, não remanescendo dúvidas acerca do porte de drogas. Ressalte-se que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Não é demais ressaltar que o acusado reconheceu a posse da droga seja Ademais, os policiais não conheciam o acusado e não teriam motivo algum para falsamente incriminá-lo. Neste sentido: "Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes." (RT 411/266).

Inexistindo indício de que o réu viabilizaria o entorpecente para consumo de terceiros, conclui-se tratar de posse para consumo pessoal.

No mais, não há que se falar na inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque, o julgamento do RE 635.659/SP, com repercussão geral reconhecida, ainda não foi concluído pela Suprema Corte.

A despeito da prolação dos votos a favor da inconstitucionalidade do referido dispositivo, sob o prisma do princípio da lesividade, o julgamento ainda se encontra suspenso. Por este ângulo, portanto, subsiste a presunção de constitucionalidade da norma.

Não se ignora a possibilidade de utilização do mecanismo de controle difuso e incidental da norma pelo magistrado, inclusive, reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, incabível in casu, porquanto permanece assente nos órgãos colegiados do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao menos por ora, o entendimento acerca da plena constitucionalidade do dispositivo em discussão.

Acerca do assunto, eis o entendimento:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ou porte de drogas para uso pessoal – Artigo 28 da Lei de Drogas. 1. PRELIMINAR – Inconstitucionalidade do referido artigo – Não cabimento – Precedentes – Devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da criminalização da posse ou porte de drogas para uso próprio – PRELIMINAR REJEITADA 2. MÉRITO – Absolvição por atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Prestação de serviços à comunidade – Adequada à espécie – APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1515307-96.2019.8.26.0019, Rel. Des. Silmar Fernandes, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 23/09/2021, DJe 23/09/2021)

Nesse sentido, contemplando a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, diante da ausência de conclusão do RE 635.659/SP, inviável o êxito da tese de atipicidade da conduta. De igual modo, não vinga o pleito de aplicação do princípio da insignificância à hipótese, porquanto a quantidade da droga não exime o acusado da responsabilização criminal, mormente porque se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado se circunscreve à saúde pública, tornando irrelevante, destarte, a quantidade de substância encontrada.

Aliás, não é outro o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie. 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida.

Precedentes 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no RHC 147158/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Finalmente, a despeito do aduzido pela nobre defesa em suas alegações finais, não há quaisquer provas acerca de eventual inimizabilidade do réu, que só poderia ser reconhecida mediante prova pericial especialmente produzida para aferição da capacidade de entendimento da ilicitude e determinação de acordo com tal entendimento, prova esta que não foi requerida. Outrossim, eventual dependência química do réu não afasta a culpabilidade, em consonância com o artigo 28, inciso II, do Código Penal, que é claro ao dispor que a embriaguez, voluntária ou culposa, por álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Ademais, não se deve olvidar que as medidas previstas no artigo 28 da Lei 11.343/2006, legislação especial, possuem caráter sócio-educativo. Com isso, e considerando que o conjunto probatório confere veracidade aos fatos descritos na denúncia, de rigor a procedência do pedido acusatório.

Passa-se ao cálculo da pena.

De início, o processo 0000633-84.2015 da 01ª Vara Criminal do Foro de Suzano (fl. 43), em que proferida sentença condenatória em desfavor do acusado, encontra-se em grau de recurso. À míngua do trânsito em julgado de referida condenação, ela não se presta a fundar reincidência ou má-antecedência do réu.

Assim, analisando-se os antecedentes do acusado, observa-se que o réu ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado (fls. 35/43).

A primeira, oriunda do processo 0003289-92.2001 da 23ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, pela prática do crime previsto no artigo 10, §3º, Lei 9437/97, com trânsito em julgado em 31/02/2002, data anterior ao fato que aqui se julga e fim da execução em 05/02/2003.

A segunda, decorrente do processo 00104394-88.2012 da 31ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, pela prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal, com trânsito em julgado em 26/04/2013, data anterior ao fato que aqui se julga e extinção da pena em 01/07/2015 (fl. 42).

Tendo em vista o decurso de mais de cinco anos desde a extinção de ambas as penas e a data do fato que aqui se julga, tais condenações não se prestam a fundar reincidência e serão tomadas como maus antecedentes.

Nesse sentido, pontue-se o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593818, com repercussão geral, firmou o entendimento de que o prazo quinquenal de prescrição na reincidência não se aplica aos maus antecedentes. Confira-se: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Deste modo, conclui-se que o réu se trata de indivíduo primário e que ostenta dois maus antecedentes.

Na primeira fase da dosimetria, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, vislumbra-se que a conduta do acusado se manteve adstrita à reprovabilidade inerente à gravidade abstrata do delito. De outro passo, havendo duas condenações a ensejar mau antecedente, a pena não pode ser a mínima. Nesse sentido, reputo aconselhável a pena de comparecimento a programa educativo relacionado à prevenção/tratamento do uso de entorpecentes. Pontue-se que um dos maus antecedentes do réu obsta a fixação da pena mínima de advertência. O outro, será considerado no cálculo do prazo da medida, nos moldes do art. 28, III da Lei 11.343/2006. Assim, ao cabo da primeira fase da dosimetria, fixo a pena de comparecimento a programa educativo relacionado à prevenção/tratamento do uso de entorpecentes pelo período de 01 (um) mês e 25 (cinco) dias.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, vez que o réu admitiu o fato ao juízo, quando interrogado. Tal atenuante ensejará a redução do prazo de comparecimento supra cominado em 1/6 (um sexto), chegando-se, ao cabo da segunda fase, à pena de comparecimento a programa educativo relacionado à prevenção/tratamento do uso de entorpecentes pelo prazo de 01 (um) mês.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição a aplicar, tornando definitiva a sanção de comparecimento a programa educativo relacionado à prevenção/tratamento do uso de entorpecentes pelo prazo de 01 (um) mês (art. 28,

III, da Lei de 11.343/2006), na forma a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu Marco Aurélio Sprocato, portador do RG n. 26.746.378/SSP/SP, filho de Aurélio Sprocato Filho e de Ângela Conceição Crispim Sprocato, nascido em 07 de agosto de 1975, natural de São Paulo/SP, à pena de comparecimento a programa educativo relacionado à prevenção/tratamento do uso de entorpecentes pelo prazo de 01 (um) mês, com fulcro no artigo 28, III, da Lei de 11.343/2006, na forma a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Ante a natureza da pena ora aplicada, reconheço o direito de recorrer em liberdade. Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração com comunicação à autoridade policial, caso tal providência não tenha sido adotada.

Custas na forma da Lei 9099/95. Por oportuno, defiro ao réu os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois, conforme informado em audiência, o acusado encontra-se desempregado, foi assistido pela Defensoria Pública e não restou demonstradas posses incompatíveis com a hipossuficiência alegada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários à patrona dativa, no patamar máximo da tabela.

Ciência ao MP e à Defesa (DPE).

P.I.

São Paulo, 28 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA